

1500284-60.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... dos réus, no tocante aos delitos de tráfico de associação para o tráfico, e a absolvição no tocante ao delito de uso de documento falso por se tratar de crime impossível.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1500284-60.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500284-60.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARY COSTA MENDES e outro

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

ARY COSTA MENDES e WALTER RAMOS FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, e no artigo 304 do Código Penal.

Segundo relata a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 16hs40min, na Rua Kasumo Sumizomo, nº 853, Mogi das Cruzes/SP, ARY COSTA MENDES e WALTER RAMOS

FERREIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 12 tabletes de Cannabis Sativa L contendo 8.794,38g, substância entorpecente listada na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Consta, também que, em data indeterminada até o dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 16hs40min, na Rua Kasumo Sumizomo, nº 853, Mogi das Cruzes/SP, ARY COSTA MENDES e WALTER RAMOS FERREIRA associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ARY COSTA MENDES e WALTER RAMOS FERREIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, possuíam uma arma de fogo do tipo revólver, marca Rossi, calibre .38, de uso permitido, e 28 (vinte e oito) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ARY COSTA MENDES e WALTER RAMOS FERREIRA fizeram uso de documentos públicos falsos.

Recebida a denúncia (fls. 122/124), os réus foram regularmente citados (fls. 170 e 172) e apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 129/136).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foram realizados os interrogatórios dos réus (fls. 184/185).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados, sustentando a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A defesa dos acusados apresentou alegações finais às fls. 385/399, oportunidade em que inicialmente pleiteou a nulidade processual diante da ilicitude da prova colhida. No mérito, pleiteou a absolvição dos réus, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa própria, no tocante ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03; a inexistência de prova suficiente nos autos para ensejar a condenação dos réus, no tocante aos delitos de tráfico de associação para o tráfico, e a absolvição no tocante ao delito de uso de documento falso por se tratar de crime impossível.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/26, pelo laudo de constatação de fls. 30/33, pelo laudo do local de fls. 184/193, pelo laudo documentoscópico de fls. 194/197, pelos laudos periciais de fls. 198/201 e 238/253, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 222/224, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos delitos é incontroversa.

O acusado Ary Costa Mendes confessou que utilizava documento falso para trabalhar, que guardava uma arma e munições em sua residência e que a droga encontrada em sua residência era sua para consumo pessoal, a qual tinha encontrado em uma pescaria. Disse ter consentido que os policiais ingressassem em sua residência e que não possui antecedentes criminais.

O acusado Walter Ramos Ferreira confessou apenas a utilização de documento falso, informando que adquiriu o documento contrafeito para viajar a este Estado. Disse que, no dia dos fatos, veio até esta cidade a convite do corréu, tendo passado o dia na casa de Ary e, quando retornava para São Paulo para voltar ao Estado de Minas Gerais foi abordado pelos policiais. Contou que os policiais quando o abordaram já o encaminharam para a delegacia de polícia, sendo que outros policiais conduziram o corréu Ary apresentando-o na delegacia de polícia cerca de quarenta minutos depois. Disse conhecer o corréu desde a infância, desconhecendo seus antecedentes criminais. Por fim, informou não possuir antecedentes criminais.

No caso em tela, as provas produzidas em Juízo permitem de maneira segura concluir pela prática dos delitos pelos réus.

O policial militar Antonio Celso da Silva Batista Mimosa contou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou dois indivíduos em uma moto, sendo que o condutor empregava alta velocidade, de modo que resolveu abordá-los. Disse que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, tendo os acusados apresentado documentos pessoais, causando suspeita o documento apresentado pelo corréu Walter. Contou que os acusados disseram que ostentavam antecedentes criminais no Estado de Minas Gerais, razão pela qual utilizavam documentos contrafeitos e que os documentos originais estariam na residência de Ary, local em que a equipe policial se dirigiu. Disse que em revista domiciliar apreendeu grande quantidade de maconha, cerca de 9 quilos, um revólver calibre .38, munições, dois mil reais em espécie, além de inúmeros pares de calçados sem comprovação lícita. Indagado o acusado Ary, informou que a droga localizada em sua residência pertencia ao corréu Walter. Não sabe informar quem efetuou a revista domiciliar dentre os policiais.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Isaac Marques Motta. Este relatou que estava em patrulhamento quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade, razão pela qual decidiu abordá-los. Disse que ao verificar a documentação entregue pelos indivíduos, sendo uma delas cópia, um dos acusados confessou que a documentação apresentada não era verdadeira e que os originais estariam em sua residência, local para onde se dirigiu. Contou que na residência localizou em uma mala um revólver calibre .38, munições, 12 tabletes de maconha, certa quantia em dinheiro, além de inúmeros calçados, sem comprovação lícita. Disse ter consultado o banco de dados da polícia militar em relação a ambos, sendo que o espelho de um dos documentos apresentado era verdadeiro, porém os dados nele inseridos eram falsos.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

“Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.”

(Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)”

Inicialmente, é de se destacar a apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do corréu Ary, circunstância que evidencia a prática do crime de tráfico de drogas.

Saliento, ainda, que não há qualquer motivo concreto para infirmar a veracidade das declarações dos policiais.

Estes, em Juízo, apresentaram relatos coesos e uníssonos afirmando que foi apreendido na residência de Ary grande quantidade de droga, ou seja, 8.794,38 gramas de “maconha”, além da quantia de R\$ 2.000,00 em espécie, a demonstrar que não se tratava de entorpecentes para consumo pessoal.

Não há como se crer que policiais, no exercício regular de suas funções, sem qualquer motivo concreto, fossem prender os acusados e acusá-los falsamente do crime de tráfico.

Ademais, além de pouco provável que o acusado Ary tenha encontrado os entorpecentes quando teria realizado uma pescaria e levado para sua casa para consumo pessoal, cabia à defesa demonstrar sua alegação, ônus do qual não se desincumbiu.

Pois bem, as declarações dos policiais, a apreensão de grande quantidade de entorpecente e de quantia considerável em dinheiro, sem comprovação lícita, revelam, de forma inequívoca, a autoria com relação ao tráfico.

Ainda, segundo o policial Antônio, Ary alegou que a droga era de Walter. Contudo, em Juízo, sem qualquer justificativa plausível, Ary alterou seu depoimento dizendo que o entorpecente lhe pertencia.

Assim, a versão dos acusados, além de inverossímil, restou isolada nos autos, não tendo a defesa trazido qualquer elemento que pudesse corroborá-la.

A natureza e a enorme quantidade do entorpecente apreendido, a quantia em dinheiro também apreendida, conforme auto de exibição e apreensão, evidenciam a prática de mercancia ilícita pelos réus.

Ressalto que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão.

Além disso, não há qualquer nulidade do ato praticado pelos policiais.

Em que pese a inviolabilidade do domicílio constituir um direito constitucionalmente protegido (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), é certo que referido direito não é absoluto, tanto que a própria Carta Magna excepciona a regra da inviolabilidade em algumas situações, dentre as quais inclui-se a de flagrante delito.

Essa é exatamente a hipótese dos autos.

Considerando que as condutas imputadas aos acusados caracterizam por ser crime permanente, isto é, cuja consumação se protraí no tempo enquanto estiver sendo praticada a conduta, verifica-se que a hipótese era de flagrante delito, portanto, desnecessária a autorização do morador ou mesmo de decisão judicial para ingressar no imóvel.

Neste sentido a jurisprudência do S.T.J.:

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na modalidade guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada” (HC 373.388/RS, DJe 01/02/2017).

Segundo relato dos policiais o ingresso na residência somente ocorreu após prévio consentimento do acusado Ary. Ademais, o próprio acusado Ary em Juízo disse ter consentido para que os policiais ingressassem em sua residência.

Dessa forma, não se verificou qualquer tipo de irregularidade na ação dos policiais, os quais agiram nos estritos limites legais e constitucionais.

Ficou, outrossim, sobejamente comprovado que os acusados agiam em associação criminosa com a finalidade de comercializar drogas, incumbindo a cada um o exercício de uma atividade distinta dentro da organização.

Com efeito, o delito de associação para o tráfico exige para a sua consumação a estabilidade das relações entre os agentes, devendo existir um caráter duradouro e estável, ajustados para a finalidade de comercialização de entorpecentes.

Como esclarece Guilherme de Souza Nucci, “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 414).

As provas são seguras acerca do vínculo associativo dos réus e ficaram comprovadas não só pelos depoimentos prestados, como também pela quantidade de drogas apreendidas, além da apreensão de apetrechos comumente utilizados para o tráfico.

Assim, constata-se que não houve o mero concurso de agentes, mas sim evidenciadas a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do delito de associação.

No caso em tela, também ficou devidamente comprovado que os acusados possuíam a arma de fogo e as munições apreendidas, não havendo qualquer prova acerca de eventual excludente de ilicitude.

Por fim, a pistola apreendida era apta a efetuar disparos, uma vez que o laudo pericial juntado às fls. 175/179 atesta que, quando dos ensaios realizados, a arma apresentou-se eficaz.

Diante dos fatos acima expostos, imperiosa a condenação dos acusados pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Também imperiosa a condenação dos acusados pelo delito previsto no artigo 304 do Código Penal.

Ficou devidamente comprovado o fato de que os acusados fizeram uso de documento público ideologicamente falsificado, sendo evidente a ciência da falsidade por parte deles, até mesmo diante da confissão de ambos.

Neste sentido:

“Para a configuração do delito do art. 304 do CP, exige-se apenas o dolo genérico

que compreende, obviamente, a ciência da falsidade do documento" (TJSP - AC - Rel. Des. Márcio Bonilha - RT 490/311).

De outro lado, para a condenação do crime de falso basta a potencialidade para se enganar e prejudicar, não se exigindo prova do dano efetivo.

Vale destacar, não ser grosseira a falsificação, embora tenham os policiais suspeitado da falsidade. Os policiais militares confirmaram que a falsificação não foi constatada de imediato, tendo que tomarem providências para sua constatação realizando consultas no sistema de informação da polícia militar.

O laudo de fls. 194/197, por sua vez, evidenciou a falsidade do documento apreendido apresentado pelo corréu Walter contendo a sua fotografia e o nome WESLEY BRAGA PEREIRA. Já o correu Ary apresentou uma carteira de habilitação, com espelho autêntico (fls. 194/197), contendo a sua fotografia e o nome falso ALISSON FIUZA DA SILVA.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade do delito, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime, em especial a grande quantidade de droga apreendida (8.794,38 gramas), além dos maus antecedentes (fls. 313/314 - autos nº 0317483-32.2013.8.13.0145), fixo a pena-base em relação ao réu Walter aumentada em um terço, vale dizer, pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no tocante ao delito de tráfico de drogas e, em relação ao acusado Ary, levando-se em conta as circunstâncias acima mencionadas e diante de seus péssimos antecedentes (fls. 322 - autos nº 0011962-43.2017.8.13.0145, fls. 323 - autos nº 0011988-41.2017.8.13.0145, fls. 350 - autos nº 0033575-76.2014.8.13.0452, fls. 351 - autos nº 0010909-13.2016.8.26.0452), fixo a pena-base aumentada em metade, ou seja, pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias- multa.

No tocante aos crimes previstos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 304 c.c. 297, ambos do Código Penal, em relação ao réu Walter, levando-se em conta seus maus antecedentes (fls. 313/314 - autos nº 0317483-32.2013.8.13.0145), fixo a pena-base aumentada em um sexto, isto é, pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (artigo 35 da Lei nº 11.343/06); pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) e pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa (artigo 304 c.c. 297, ambos do Código Penal); em relação ao acusado Ary, diante de seus péssimos antecedentes (fls. 322 - autos nº 0011962-43.2017.8.13.0145, fls. 323 - autos nº 0011988-41.2017.8.13.0145, fls. 350 - autos nº 0033575-76.2014.8.13.0452, fls. 351 - autos nº 0010909-13.2016.8.26.0452), fixo a pena-base aumentada em um terço, isto é, pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa (artigo 35 da Lei nº 11.343/06); pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) e pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa (artigo 304 c.c. 297, ambos do Código Penal).

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência em relação ao corréu Ary (fls. 319/320 - autos nº 0016146-76.2016.8.13.0145), razão pela qual aumento as penas em um sexto, alcançando a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 875 (oitocentos e

setenta e cinco) dias-multa (artigo 33 da Lei nº 11.343/06); pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 1088 (um mil e oitenta e oito) dias-multa (artigo 35 da Lei nº 11.343/06); pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) e pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa (artigo 304 c.c. 297, ambos do Código Penal).

A pena permanece inalterada na segunda fase de fixação da pena em relação ao corréu Walter.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que os réus não preenchem os requisitos exigidos, uma vez que a grande quantidade de droga apreendida e a associação criminosa na prática do tráfico de drogas, demonstram que possuem ligação com atividades criminosas.

Não há como se crer que os acusados teriam acesso a grande quantidade de drogas, atuando de forma organizada e estruturada, sem que tivessem qualquer tipo de vínculo com organização criminosa. Ademais, o acusado Ary é reincidente e possuidor de péssimos antecedentes, enquanto o acusado Walter ostenta maus antecedentes.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça "Configurado o crime de associação para o tráfico, fica vedada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal" (HC 349.8378/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJ 03/05/2016).

Incabível, pois, a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

"O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais. No âmbito desta Colenda Câmara, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que "essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma

rotina de proceder". A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)."

No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

"Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas".

Os crimes devem ser tidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que foram praticados mediante diversas condutas, com objetividade jurídica distintas.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverão os réus iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo):

"O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países

com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios”.

Em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 os réus deverão iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, §3º, e artigo 59, ambos do Código Penal, uma vez que se trata do regime mais adequado como forma de retribuição e prevenção.

Com efeito, os elementos colhidos nos presentes autos deixam evidente o fato de que os réus são pessoas de destacada periculosidade, já tendo sido condenados definitivamente pela prática de outros crimes.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP.

Destarte, os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado no tocante aos delitos de tráfico e associação para o tráfico e posse ilegal de arma, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, ante todas as razões já expostas.

De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade dos acusados, que ficou claramente evidenciada nos autos.

Não há elementos para formar a convicção de que atenderiam ao futuro chamado judicial se fossem, agora, colocados em liberdade, mormente após a condenação.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 70/71.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar:

- ARY COSTA MENDES como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.978 (um mil, novecentos e setenta e oito) dias-multa; e ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa;

- WALTER RAMOS FERREIRA como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.493 (um mil, quatrocentos e noventa e três) dias-multa; e ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade aos acusados, ante as razões expostas.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram.

Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Por fim, determino o perdimento da quantia apreendida e da motocicleta em favor da União, a destruição dos objetos apreendidos, bem como a incineração dos entorpecentes.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 19 de maio de 2022.